

1502028-83.2020.8.26.0544

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: MAURICIO GARIBE

Comarca: Jundiaí / SP

Foro: Foro de Jundiaí

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/05/2022

... entendimento em relação aos crimes de 'tráfico privilegiado' (aqueles cometidos por agente primário e de 'bons antecedentes', que não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa).

Assim, aplico o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, isto é, será considerado crime de natureza comum o 'tráfico privilegiado'.

Por fim, considerando ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jundiaí / SP - 1ª Vara Criminal

Largo São Bento, s/nº, Centro - CEP 13201-035, Jundiaí-SP

Fone: (11) 4586-8111 - E-mail: jundiai1cr@tjsp.jus.br

Horário de atendimento ao público: 13h00min às 17h00min

1502028-83.2020.8.26.0544 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1502028-83.2020.8.26.0544 - controle nº 2020/001707

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RYAN FELIPE MARINHO DA SILVA e outro

Juiz de Direito: MAURICIO GARIBE

Vistos.

Referente ao Recurso Especial nº 1984656/SP (2022/0038663/2)

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Trata-se de decisão proferida nos autos em epígrafe, em que são recorrentes GUILHERME ELIVELTON DOS SANTOS CARDOSO DE ALMEIDA e RYAN FELIPE MARINHO DA SILVA, determinando o refazimento da dosimetria da pena, por este Juízo, de acordo com as premissas ali indicadas, afastando a circunstância agravante da calamidade pública com relação a ambos os recorrentes e reconhecendo o direito do recorrente Ryan Felipe à consideração da aplicação da causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, analisando também, com a devida motivação, a possibilidade de conversão da pena em restritiva de direitos e o regime inicial adequado à nova pena fixada.

Em primeiro grau, o recorrente RYAN FELIPE MARINHO DA SILVA foi condenado por infração ao disposto no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/2006, a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade aplicada por pena restritiva de direitos,

consistente na prestação de serviços à comunidade, por igual período, nos termos em que fixada pelo Juízo das Execuções Criminais da Comarca, porque no dia 27 de setembro de 2020, por volta das 14h30min., na Rua Angélica Queirós Guimarães, n. 1, Vila Maringá, nesta cidade e comarca de Jundiaí, estariam trazendo consigo, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar 3,84 g de cocaína, na forma de crack, divididos em 24 vítresos fechados (lacre 20051), além da quantia de R\$ 62,50, em dinheiro. Já o recorrente GUILHERME ELIVELTON DOS SANTOS CARDOSO DE ALMEIDA foi absolvido da imputação de infringência ao artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, c.c. o artigo 61, inciso II, alínea "j" (calamidade pública), do Código Penal, com fundamento no disposto do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Irresignado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação, ao qual foi dado parcial provimento para aumentar a pena do réu Ryan Felipe Marinho da Silva para 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, e 500 dias-multa, e para condenar Guilherme Elivelton dos Santos Cardoso de Almeida como incurso no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/06, a 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime aberto e 194 dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade, por igual período, e por prestação pecuniária, no importe de um salário mínimo.

A Defesa opôs embargos de declaração da decisão, os quais foram conhecidos e rejeitados.

Ademais, interpôs recurso especial, ao qual foi dado provimento para afastar a agravante da calamidade pública e reconhecer o direito do recorrente Ryan Felipe Marinho da Silva à consideração, na dosimetria da pena, da aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Desta forma, em cumprimento à determinação da Corte Superior passo ao reexame dos requisitos do artigo 59 do Código Penal e, em tal contexto, retifico a dosimetria da pena para constar:

"Na primeira fase, observo que os réus são primários e sem antecedentes criminais, razão pela qual fixo sua pena no mínimo legal previsto para o crime que lhes é imputado, estabelecendo-a em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, estabelecida a unidade no piso mínimo.

Na segunda fase, com relação ao acusado Guilherme Elivelton, ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes a considerar, razão pela qual, nesta fase de dosimetria, a pena-base fixada deve ser mantida.

Já com relação ao corréu Ryan Felipe, ausentes agravantes, fazem-se presentes a atenuante genérica da confissão espontânea, bem como a da menoridade relativa. Contudo, consoante a Súmula 231 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a incidência de atenuantes não pode conduzir à redução da pena aquém do mínimo legal, razão pela qual, nesta fase da dosimetria da pena, deve ser mantida a pena base fixada.

Considerando a incidência da causa de diminuição de pena prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Tóxicos, diminuo as penas aplicadas em 2/3 (dois terços), estabelecendo-as em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, mantida a unidade no mínimo, pena esta que torno definitiva ante a ausência de modificadoras a considerar.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça (julgamento da Petição nº 11.796/DF), após parecer favorável da Procuradoria Geral da República, adotou o seguinte entendimento em relação aos crimes de 'tráfico privilegiado' (aqueles cometidos por agente primário e de 'bons antecedentes', que não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa).

Assim, aplico o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, isto é, será considerado crime de natureza comum o 'tráfico privilegiado'.

Por fim, considerando que o acusado é primário, não possui antecedentes criminais, o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça e o acusado não tem vínculo com organização criminosa, entendo possível a substituição da pena privativa de liberdade aplicada por pena restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade, por igual período, nos termos em que fixada pelo Juízo das

Execuções Criminais da Comarca, conforme o artigo 44 do Código Penal.

Nesse particular, consigno que, conquanto a pena privativa de liberdade cominada seja superior a 1 (um) ano, foi procedida sua substituição por uma única pena restritiva de direitos.

Ora, a substituição das penas privativas de liberdade por penas restritivas de direito é direito subjetivo do acusado, desde que se encontrem presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva estabelecidos pelo Legislador.

E, na dicção do parágrafo 2º, do artigo 44 do Código Penal, na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos; se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos.

Ou seja, não é consequência automática que a pena privativa superior a 1 (um) ano seja substituída por 2 (duas) penas restritivas, tão somente pelo montante da pena corporal.

Trata-se de faculdade atribuída ao Juiz, que poderá determinar que a substituição seja feita por uma ou por algumas penas restritivas, quando as circunstâncias do artigo 44, inciso III, do Código Penal (isto é, a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado) indicarem que essa substituição seja suficiente.

Assim, na hipótese deste processo, vejo que a substituição da pena privativa de liberdade por uma única pena restritiva de direitos mostra-se coerente e adequada à situação do acusado e às circunstâncias do crime.

Na hipótese de descumprimento da pena restritiva de direito, os acusados iniciarão o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime aberto, sendo-lhes facultado o direito de recorrer desta sentença em liberdade.

III - Dispositivo. Ante o exposto e pelo mais dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO PENAL para CONDENAR GUILHERME ELIVELTON DOS SANTOS CARDOSO DE ALMEIDA e RYAN FELIPE MARINHO DA SILVA, qualificados nos autos, por infração ao disposto no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/2006, a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade aplicada por pena restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade, por igual período, nos termos em que fixada pelo Juízo das Execuções Criminais da Comarca, fixado o regime aberto em caso de descumprimento, tudo conforme fundamentação acima."

Mantida, no mais, a sentença.

Oficie-se ao E. Tribunal de Justiça.

Jundiaí, 10 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA